

1500028-72.2022.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... dos depoimentos, em operação de combate ao tráfico de entorpecentes naquele bairro, ao ingressarem no logradouro descrito na exordial acusatória, se depararam com MARCELO e CRISTIANO, juntos, próximo a um estabelecimento comercial (Bar da Dalva), conhecido "ponto" de tráfico. Ambos, ao avistarem a presença da viatura, adotaram a mesma reação comportamental, empreendendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500028-72.2022.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500028-72.2022.8.26.0631

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007151/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 22342774 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 50/22/112 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2007151 - 01º D.P. AMPARO, 50/22/112 - 01º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO SILVA DE SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

MARCELO NUNES DOS SANTOS, devidamente qualificado (fl. 19) nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, acusado de ter, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 22h00, na Av. Orlando Audrai Barros Bueno, próximo ao numeral 456, Jardim São Dimas, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, com o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 06 (seis) porções de cocaína, pesando 5g, e 04 (quatro) porções de "crack", pesando 3,79g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar (fls. 117/119).

CRISTIANO SILVA DE SOUSA, devidamente qualificado (fl. 34) nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, acusado de ter, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 22h00, na Av. Orlando Audrai Barros Bueno, próximo ao numeral 456, Jardim São Dimas, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, com o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 10 (dez) porções de cocaína, pesando 13,35g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 117/119).

A prisão flagrancial de ambos foi convertida em preventiva (fls. 87/89)

A denúncia foi recebida em 01.02.2022 (fl. 120).

Devidamente citados (fls. 164 e 166), os acusados, por intermédio de suas D. Defensoras, apresentaram respostas por escrito à acusação (fls. 202/204 e 221/222), não arrolando testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária de nenhum dos acusados, determinou-se a abertura da fase instrutória (fls. 231/232), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas de duas testemunhas arroladas pela Acusação, seguindo-se dos interrogatórios dos acusados, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fl. 274).

Em sede de memoriais orais, a D. Promotora de Justiça requereu a parcial procedência da pretensão punitiva, com a condenação do corréu MARCELO e a desclassificação da imputação original para o crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal em relação ao acusado CRISTIANO (fl. 274).

A D. Defensora de MARCELO, também oralmente, pugnou pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, além de tecer considerações sobre pena e regime prisional.

A D. Defensora de CRISTIANO, valendo-se da forma escrita, defendendo a fragilidade no conjunto probatório, pugnou pela absolvição (fls. 275/277).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), do auto de constatação preliminar (fls. 17/18), do importe numerário apreendido (fls. 108/109), bem como e, principalmente, pelos laudos de exame químico-toxicológicos realizados nas substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 127/129, 130/132 e 133/134).

Com efeito, os laudos, corroborando o auto de constatação preliminar de substância entorpecente, confirmaram tratar-se de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, listadas na Portaria n. 344/98 SVS/MS.

As autorias, da mesma forma, não comportam dúvidas.

Vale lembrar, em primeiro lugar, que os acusados foram presos em flagrante, após serem vistos, juntos, em local conhecido como "ponto" de venda de entorpecentes, evadindo-se rapidamente ao notarem a presença da viatura policial, cada qual com certa quantidade de drogas e importância em dinheiro, razão pela qual a autoria torna-se certa, pois, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho, a prisão em

flagrante "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra "Do Flagrante Delito", 1933, p. 25.

De acordo com HÉLIO TORNAGHI, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" ("Curso de Processo Penal", 5ª ed., 49).

Ademais, a análise coligida dos elementos colhidos no caderno investigativo e produzidos sob o crivo do contraditório permite concluir pela responsabilidade penal dos agentes. Vejamos.

José Eduardo Rocha, policial militar, contou que na data dos fatos estava em uma operação conjunta com as demais forças de segurança, quando, em patrulhamento pelo Bairro São Dimas, ao ingressar naquela rua, avistou os dois réus, juntos, próximo ao Bar da Dalva, local conhecido como "ponto" de tráfico, de forma que ambos, ao notarem a presença da viatura, fugiram. MARCELO correu, sendo perseguido e alcançado pela equipe do depoente. Abordado, foi apreendido em seu poder 06 porções de cocaína e 04 porções de "crack", além de R\$280,00 em dinheiro. CRISTIANO também correu, mas em direção à uma viela, sendo perseguido pelos policiais que estavam de moto. Ao ser alcançado, tentou engolir os entorpecentes, tratando-se de 01 invólucro, contendo em seu interior 10 porções de cocaína, estando, ainda, em poder de R\$10,00. Ambos os acusados já eram conhecidos nos "meios" policiais, não sendo a primeira vez que os abordava.

Atílio José da Costa, colega de farda, confirmou que estava em uma operação de combate ao tráfico naquele bairro. Próximo a um bar, os dois réus foram vistos e, ao perceberem a presença dos policiais, fugiram, cada qual para um rumo. MARCELO foi abordado pela equipe que o depoente integrava, sendo encontrado em poder dele "crack" e cocaína, além de certa quantia de dinheiro. CRISTIANO correu na direção de uma viela, sendo alcançado por outra equipe, sendo abordado em poder de "crack".

Passemos aos interrogatórios.

Silente em solo policial (fl. 06), em juízo MARCELO confessou a propriedade do dinheiro e de todo o entorpecente ("crack" e cocaína) apreendido em seu poder, o qual, segundo ele, realmente era destinado ao tráfico.

Assim como já havia feito em solo policial (fls. 08), em juízo, CRISTIANO confirmou a propriedade dos entorpecentes, dez porções de cocaína, sustentando que seriam para seu uso. Havia acabado de adquirir aquelas drogas - não do corréu MARCELO - e quando se dirigia para consumi-las foi surpreendido pelos policiais, de forma que, assustado e por ter "saído do sistema", fugiu da abordagem.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Os policiais que participaram da ocorrência demonstraram muita segurança em seus relatos, apresentando detalhes substanciais que evidenciam conhecimento do caso e precisão quanto à dinâmica fática. Em versões harmônicas e que se completaram, atribuíram aos acusados a prática delitiva.

Segundo se depreende da análise coligida dos depoimentos, em operação de combate ao tráfico de entorpecentes naquele bairro, ao ingressarem no logradouro descrito na exordial acusatória, se depararam com MARCELO e CRISTIANO, juntos, próximo a um estabelecimento comercial (Bar da Dalva), conhecido "ponto" de tráfico. Ambos, ao avistarem a presença da viatura, adotaram a mesma reação comportamental, empreendendo fuga, cada qual adotando um rumo distinto.

MARCELO foi perseguido e abordado pela equipe das testemunhas ouvidas em audiência,

sendo localizado em poder de 06 porções de cocaína e 04 pedras de "crack", além de R\$280,00 em dinheiro. Interrogado em juízo, ele confessou a propriedade do dinheiro e dos referidos entorpecentes, assim como o destino mercantil que para eles conferiria.

CRISTIANO fugiu em outro sentido. Mais astuto, até por já contar com condenações anteriores por tráfico, ingressou em uma viela por imaginar que, assim, os policiais, estando em viatura, não conseguiriam persegui-lo. De fato, seu raciocínio se mostrou correto, porém ele não contava com a existência de uma outra equipe de policiais, em motos (Rocam), que saíram em seu encalço e o alcançaram. Desesperado, por ter deixado o sistema prisional há pouco tempo, tentou engolir o invólucro que trazia consigo, contendo 10 pedras de "crack", sem, contudo, obter êxito. Interrogado, alegou não estar na companhia de MARCELO quando da chegada dos policiais e, quanto às drogas apreendidas em seu poder, havia acabado de adquiri-las para o uso pessoal, sendo abordado ao tempo em que se dirigia para consumi-las em uma viela.

Lembro que o policial José Eduardo Rocha pontuou que ambos já eram conhecido nos "meios" policiais, suportando anteriores abordagens.

É certo que a prova oral colhida durante a instrução baseia-se, principalmente nos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, mas, vem sendo pacificada a repulsa nas Egrégias Cortes, com lastro do maior quilate na Superior Instância e na Extraordinária em especial, quanto à alegação de imprestabilidade dos depoimentos dos policiais que participam da diligência que culminou com a prisão dos acusados.

Tal insistência visa ressuscitar uma velharia nociva prejudicial, em recalçar, atribuindo-se ao Estado, a desinteligência de conferir a tais agentes o encargo importantíssimo de coibir o crime, mas, lhes recusar credibilidade para testemunhar.

Assim, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pelos policiais, haja vista não contarmos com informações que desabonem ou desprestigiem suas condutas e formas de atuação, tampouco para que atribuíssem aos réus os fatos, incriminando-os maliciosa ou levemente.

Ademais, não se provou, nem se invocou com concretude, algo em que se baseasse alguma das hipóteses de válido repúdio a ditos testemunhos, a inverosimilhança ou o entrechoque com outras provas.

A negativa do réu CRISTIANO não se sustenta.

Isto porque, adotou a mesma reação comportamental de MARCELO, fugindo na direção de uma viela para evitar a aproximação dos policiais, com a viatura, tendo, ainda, tentado engolir as 10 pedras de "crack", que estavam dentro de um invólucro, forma de acondicionamento típica de quem comercializa drogas.

A tentativa de se desvencilhar da companhia de MARCELO, situação fática-geográfica confirmada pelos policiais em audiência, bem como a alegação de se tratar de mero usuário, revelam nítida intenção de se eximir da responsabilidade criminal, algo esperado diante do seu histórico criminal.

Ademais, não é crível que alguém que ainda cumpra pena, já advertido das condições do seu regime prisional, perambule, gratuitamente, com 10 (dez) porções de cocaína, embaladas individualmente, cuja quantidade, diversamente do sustentado pela representante do Ministério Público, não é tão diminuta.

Frágil e costumeira a evasiva do acusado preso em um mesmo cenário, comuns à esse tipo de demanda criminal (tráfico). Nunca estão juntos; sempre flagrados em "ponto" de comercialização de drogas; nunca justificam, a contento, os motivos pelos quais

tentaram fugir quando visualizaram a viatura policial e, a respeito do dinheiro, sempre atribuem origem à "bicos" ou auxílios governamentais.

Frise-se, ainda, já se decidiu que, "para se identificar o traficante e distingui-lo do usuário, não é só o problema da quantidade que se deve levar em conta. Os próprios traficantes raramente são encontrados com grandes quantias de tóxicos, pois se de um lado não pretendem correr o risco de perder tudo, numa investida policial, ou de outro a pequena quantidade pode prestar-se a vendas a varejo e mesmo a dissimulação do característico de mercancia" (Vicente Grecco Filho, in "Tóxicos", 1993, Editora Saraiva, n. 17, pág. 120, destaquei).

A conduta de trazer consigo não afasta a violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, para a consumação do crime prescinde de atos de comercialização, porque se trata de dispositivo de conteúdo variado, ou de ação múltipla, ensejando a prática do delito, em questão, a violação a qualquer uma das suas várias condutas.

É certo que o fato de não terem sido presos "vendendo" a droga é matéria irrelevante à configuração do tipo penal em questão, conforme jurisprudência torrencial a respeito, pois o entendimento francamente vencedor é no sentido de que o perigo de dano em tais casos é presumido de modo absoluto, tendo em vista o perfeitamente conhecido efeito lamentável causado pelo traficante de droga.

É evidente que o tráfico de entorpecente envolve atividades essencialmente clandestinas, daí a razão da não exigência da prova flagrancial do comércio ilícito, mas elementos, concretos, que forneçam a evidência do comércio.

Sendo assim, as circunstâncias fáticas e a prova oral colhida se mostram suficientes para a condenação dos réus pelo delito de tráfico de entorpecentes, não havendo campo para a pretendida desclassificação para o crime de porte de entorpecentes (artigo 28, da Lei 11.343/06) em relação ao corréu CRISTIANO, pena de se afrontar à prova dos autos e a boa atuação dos policiais.

E como também reconhecem os tribunais:

"Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio. "(RT 710/325).

Aliás, é sabido que a condição de usuário veiculada - sequer minimamente documentada, não exclui, a priori, por si só, a condição de traficante, somente se aplicando a desclassificação quando os elementos permitirem cabal aferição nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

Acrescente-se que nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois, como é sabido, normalmente encontram-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso o agente saia ileso do crime de maior gravidade.

A respeito, confira-se:

"(...) Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde

pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas" (REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06/03/2018).

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

MARCELO NUNES DOS SANTOS

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42, da Lei n 11.343/06, bem como da análise da sua Certidão de Eventos (fl. 246), verifico que o acusado é primário e não ostenta antecedentes conhecidos. Da mesma forma, não evidencio circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Inexistem agravantes. Presentes as atenuantes do art. 65, I e III, "d", do Código Penal, eis que ao tempo dos fatos o réu era menor de 21 anos (fl. 19) e confessou integralmente o delito, cuja redução, de 1/3 (um terço), todavia, resta prejudicada, em razão da sua reprimenda já se encontrar no patamar mínimo (Súmula nº 231 do STJ)

Ausentes causas de aumento. Reconheço em favor de MARCELO a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Efetivamente o acusado é primário e não ostenta antecedentes conhecidos. Da mesma forma, não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou que integre organização criminosa.

O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Assim, compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretarem à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a diversidade, as naturezas e a quantidade das substâncias apreendidas.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 - Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09).

Nesta esteira, atento à natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e "crack"), com efeitos deletérios à saúde humana e alta procura entre usuários, é que a redução deverá ser feita na proporção intermediária, de 1/2 (metade).

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Mesmo conhecedor do posicionamento do C. STF exarado no HC 118.533 (23.06.16) decidindo não ser o "tráfico-privilegiado" de natureza assemelhada ao crime hediondo, é posicionamento deste julgador que o caso em apreço reclama a imposição de regime INICIAL FECHADO, até porque o réu desenvolvia atividade ilícita em local público, na companhia de outro indivíduo, experiente, que já contava com condenação pela prática do mesmo crime.

Cabe invocar ensinamento daquela mesma Corte Suprema: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59" .

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena, tornando-a inócua, mormente frente ao seu retorno precoce à sociedade, com a sensação de Justiça banalizada.

Lembro, por fim, que a imposição coletiva vinculante quanto à vedação de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta aos condenados pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, determinada pelo voto monocrático de lavra do E. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz (6ªT do C. STJ) em sede de HC nº 596.603/SP, foi CASSADA pela r. decisão exarada pelo Exmo. Ministro do C. STF, Alexandre de Moraes, ao tempo do julgamento do RE nº 1.344.374, em 1º/12/2021, conferindo ao julgador a liberdade de avaliar o regime prisional cabível em cada caso.

CRISTIANO SILVA DE SOUZA

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como da análise da sua Certidão de Eventos (fls. 247/250), entendo inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Na segunda fase, presente em desfavor de CRISTIANO, a agravante prevista no art. 61, inciso I do CP. Isto porque, ao tempo do fato ele já ostentava duas condenações, pelo mesmo crime, com trânsito em julgado (autos nº 0002959-82.2017.8.26.0022 - fl. 248 e nº 1500135-87.2020.8.26.0631 - fl. 249), nos exatos termos dos arts. 63 CC 64, inciso I, ambos do CP, cujo aumento será de 1/2 (metade), frente a quantidade e especificidade em ambas.

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição, notadamente aquela prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, frente à reincidência específica.

Pelas mesmas razões acima expostas, agregado ao fato de CRISTIANO ser reincidente específico, o regime, para cumprimento da pena privativa de liberdade, não pode ser outro que o inicial FECHADO.

Por fim, no caso de ambos, NÃO há que se falar em aplicação do artigo 387, §2º, do CPP, devendo a progressão do regime ser analisada pelo juízo da execução, competente para tanto, na medida em que detém as informações necessárias, sob os prismas objetivo (cálculo de pena) e subjetivo (comportamento carcerário) para enfrentar a questão.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para:

A) CONDENAR o réu MARCELO NUNES DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do §2º do art. 49, por infração ao delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

B) CONDENAR o réu CRISTIANO SILVA DE SOUZA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do §2º do art. 49, por infração ao delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Justifico.

Em relação ao acusado CRISTIANO, o montante total de pena ultrapassa o limite máximo permitido em lei (art. 44, I, do CP), além de ele se mostrar reincidente específico em crime doloso (art. 44, II, do CPC)

O acusado MARCELO também não faz jus.

Não se desconhece que em 01.09.2010 o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação legal à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes regulados na Lei Federal nº 11.343/2006. O emblemático leading case coube ao "Habeas Corpus" nº 97.256, impetrado pela Defensoria Pública da União no município de Porto Alegre-RS.

Também não passa despercebido que o Senado Federal, recentemente, promulgou no dia 15 de fevereiro a Resolução nº 05 de 2012, suspendendo, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Todavia, salvo raríssimas e excepcionais situações, a condição de traficante inviabiliza o agraciamento do agente com a substituição em voga, pois o comercializador de drogas, desprovido de senso moral e religioso, destruidor de lares e famílias, não preenche os requisitos subjetivos estampados em lei.

O tráfico de drogas apresenta lucros incalculáveis e prejuízos incontáveis à ferida sociedade, tratando-se de mercancia vil, de intensa potencialidade lesiva para a saúde pública e para a sociedade.

Tal constatação vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, exigido, cumulativamente a outros, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nesse sentido:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a

diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ªT, j. 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Aliás, bem ressaltou o Eminentíssimo Desembargador Ricardo Tucunduva, "...o tráfico de drogas é delito incompatível com tais benefícios, podendo o legislador, então impor maior rigor na sanção aplicada aos seus infratores, em prol dos interesses da população ordeira e trabalhadora de nosso país..." (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal, Ap. nº 0000472-64.2011.8.26.0115, j. 02.02.12).

Ademais, não nos parece ter sido a intenção precípua do Poder Constituinte Originário conceder beneplácitos a crimes equiparados aos hediondos, cujo tratamento jurídico merece maior rigorismo.

A meu sentir, respeitados judicioso entendimento em sentido contrário, seria ilógico substituir penas privativas de liberdade para impor sanções restritivas de direitos a condenados por crimes hediondos ou equiparados a eles, pena de se esvaziar o tratamento mais rígido que a Lei buscou imprimir, fortalecendo a política criminal voltada a inibir a mercancia espúria de estupefacientes, que, a propósito, propaga sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país, notadamente de índole patrimonial.

Os réus tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventivas (fls. 87/89). Permaneceram presos durante a instrução processual. Ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, em especial à aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública (art. 312, caput, cc. art. 313, ambos do CPP), agora, frente ao édito condenatório suportado, a ser cumprido em regime prisional mais gravoso, com maior razão, deverão aguardar presos a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Recomendem-se os réus.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.
Com fundamento no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do importe numerário apreendido (fls. 108/109), em favor da União, expedindo-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeçam-se cartas de guia de execução (Sumula nº 716, do STF) e anatem-se as condenações definitivas no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA